

1501429-88.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... apreendidos. Que o interrogando faz tráfico na região, ou seja, no Campo acima citado. Que LUCAS é usuário de entorpecentes e estava no local no momento da abordagem e este foi abordado e revistado por policiais militares e nada de ilícito foi encontrado com LUCAS, pois este nem chegou a comprar drogas. Que o interrogando diz que faz tráfico no local por 'necessidade' pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501429-88.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501429-88.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YURI CALDEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

YURI CALDEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cc. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 15h, na Avenida Caititu, altura do n.º 617, Itaquera, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 15 (quinze) porções contendo Tetrahydrocannabinol, substância popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido aproximado de 17,16g (dezesete gramas e dezesseis decigramas); 02 (duas) porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 1,6g (um grama e seis decigramas); 32 (trinta e dois) frascos contendo tricloroetileno, substância popularmente conhecida como "lança-perfume", com quantidade aproximada de 288 ml (duzentos e oitenta e oito mililitros), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, o acusado apresentou defesa prévia, subscrita por Defensora Pública nomeada nos autos (págs. 121/122).

Recebida a denúncia (págs. 188/191), durante a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas arroladas, interrogando-se o réu ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça insistiu na condenação, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese, que a prova produzida é precária. Alternativamente, requereu: (I) fixação da pena base no mínimo legal; (II) desclassificação do crime denunciado para a figura típica prevista no art. 28 da Lei 11.343/06; (III) aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do artigo 33 da lei 11.343/06; (IV) o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão; (V) afastamento da agravante atinente ao estado de calamidade pública; (VI) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, (VII) detração; (VIII) fixação de regime de cumprimento diverso do fechado; e, por fim, (IX) seja assegurado ao réu o direito de interpor recurso em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

É procedente a presente ação penal.

A materialidade do delito veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 05 e seguintes); boletim de ocorrência (págs. 13/16); auto de exibição e apreensão (págs. 29/30); imagem das drogas, da bolsa, da quantia em espécie e anotações apreendidas (pág. 31); laudo de constatação (págs. 33/36); laudo de exame químico-toxicológico (páginas 209/212), que apontou para a presença de tetrahydrocannabinol, cocaína e tricloroetileno nas substâncias analisadas; bem como pela prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, nas oportunidades em que foi interrogado, o acusado admitiu a responsabilidade pelas drogas apreendidas em seu poder, bem como que destinadas ao comércio espúrio.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, declarou que : "...diz que estava no campo conhecido como "X DO MORRO", onde se encontrava no palco quando foi abordado por 2 pessoas, que depois soube se tratar de policiais militares e após revista foi localizado na posse do interrogando, os entorpecentes e valores apreendidos. Que o interrogando faz tráfico na região, ou seja, no Campo acima citado. Que LUCAS é usuário de entorpecentes e estava no local no momento da abordagem e este foi abordado e revistado por policiais militares e nada de ilícito foi encontrado com LUCAS, pois este nem chegou a comprar drogas. Que o interrogando diz que faz tráfico no local por 'necessidade' pelo fato de ter uma filha de 03 meses. Que o interrogando afirma que esta no tráfico há apenas duas semanas." (pág. 11).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, justificou que enfrentava dificuldades financeiras, situação que o levou a vender drogas no local em que foi flagrado, o que vinha fazendo há duas semanas.

Disse que depois que obteve a liberdade provisória passou a trabalhar com seu tio, com serviço de pintura, mas acabou desempregado novamente. Por essa razão, voltou a vender drogas em dezembro de 2021.

Ao final, questionado pelo representante do Ministério Público, disse que não intimidou os policiais, ou seja "...não fui eu que falei isso Sr, foi o Lucas, o campana...".

Acrescentou que o dinheiro apreendido em seu poder era oriundo do tráfico de drogas.

E referida confissão se ajustou aos demais elementos de prova amealhados no contraditório, sobretudo diante da segura fala da ofendida, e do minudente e insuspeito relato das testemunhas inquiridas.

Os policiais militares responsáveis pela diligência apresentaram versões coerentes e harmônicas a respeito dos fatos.

Narraram, em uníssono, de forma bastante serena e insuspeita, que diligenciavam pelo local uma vez que buscavam localizar "foragidos da justiça".

Ao chegarem ao local indicado na denúncia, visualizaram dois indivíduos conversando, entre eles o acusado, que mostrou-se incomodado pela presença da

guarnição.

Desta forma, realizaram a abordagem e localizaram, junto ao corpo do réu, uma bolsa contendo porções de drogas fracionadas e diversificadas, também certa quantia em espécie, e uma folha de papel contendo anotações sugestivas do tráfico.

Questionado, informalmente, o acusado disse que estava no local realizando a venda de entorpecentes e o rapaz que o acompanhava, Lucas, seria o responsável pela sua segurança, o campana.

Por fim, afirmaram que quando da abordagem, o acusado os intimidou, questionando-os se não tinham noção do perigo.

Como consignado, o conjunto probatório é farto na demonstração da ocorrência do crime, não deixando dúvida sobre a autoria.

O réu, nas oportunidades em que foi interrogado, confessou amplamente a imputação, admitindo que as substâncias foram apreendidas em seu poder, e destinadas ao tráfico.

Essa confissão encontrou o necessário conforto nos elementos probatórios produzidos ao longo da persecução criminal, que o incriminaram sobremaneira, sobretudo considerando o minudente relato das testemunhas policiais.

Com efeito, o réu foi surpreendido enquanto trazia consigo drogas diversificadas, fracionadas e prontas para o comércio, um aparelho celular, R\$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) em espécie, em notas trocadas, e anotações sugestivas de contabilidade de tráfico, não apresentando justificativa convincente quando instado, restando evidente que estava no local realizando o comércio espúrio que lhe foi imputado na denúncia.

No mais, os policiais inquiridos detalharam as circunstâncias da diligência que realizaram, que culminou com a prisão em flagrante do acusado portando as substâncias relacionadas na denúncia.

E os esclarecimentos apresentados pelos policiais, é sempre bom consignar, são dignos de toda credibilidade, sobretudo não existindo demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente, que sequer conheciam. Como qualquer testemunha, prestaram compromisso de dizer a verdade, e a versão que apresentaram só pode ser desprezada se existir prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido: "Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas". (TJRJ - AC - Rel Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Enfim, o conjunto probatório é bastante sólido e incrimina sobremaneira o réu, ensejando uma condenação segura.

Quanto ao tóxico apreendido, desnecessário maiores digressões acerca de sua destinação. O desiderato de mercancia é manifesto e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para dúvidas.

A forma como as drogas estavam acondicionadas - 15 (quinze) porções de maconha, 02 (duas) porções de cocaína e 32 (trinta e dois) frascos contendo tricloroetileno, substância popularmente conhecida como "lança-perfume" - e as circunstâncias do flagrante, afastam qualquer dúvida quanto a destinação, de forma que não há que se falar em desclassificação do crime denunciado para o previsto no artigo 28 da lei especial, até porque o acusado não reivindicou a posse dos entorpecentes para consumo próprio.

Assim não fosse, consigne-se que a situação de usuário de drogas não exclui a de traficante, uma vez que: "Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (TJSP - AC 9.751-3 - Rel. Gonçalves Sobrinho - RJTJSP 75/343).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade de droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão dependência, inadmissível - Inteligência dos arts. 12 e 16 da Lei 6.368/76." (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

Por esses argumentos, bem comprovada a mercancia, não há que se falar em prova precária, inviabilizando o acolhimento da pretensão absolutória da Defesa.

Demonstrada a ocorrência do delito, e comprovada a autoria, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

O acusado era tecnicamente primário à época do crime.

Não obstante, as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, uma vez que demonstrou ousadia e periculosidade, intimidando os policiais no momento em que foi flagrado, questionando-os se "...não tinham noção do perigo por estarem ali..."..

Logo, por esses fundamentos, atendendo aos critérios norteadores dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Considerando a menoridade relativa do acusado à época do crime, que contava com 18 anos, atenuo a pena para o mínimo legal.

Inciduiu, no caso concreto, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, já que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19 (Decreto Estadual nº 64.879 e Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020).

Cumpra salientar que a lei não exige nexo de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime praticado pelo agente. Para o reconhecimento da agravante em questão - objetiva - basta que o delito seja executado durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, reconhecida por meio dos decretos supramencionados, o que indica insensibilidade moral do agente e ausência de fraternidade e solidariedade social. De se ressaltar que o texto legal é expresso ao estabelecer a incidência da referida circunstância quando o crime é praticado por ocasião de qualquer calamidade pública, não exigindo nexo de causalidade.

Todavia, referida agravante fica compensada com a atenuante da confissão espontânea, já que o acusado, sempre que questionado, admitiu a responsabilidade pelo crime.

Não estão presentes os requisitos legais para a redução de pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da lei 11.343/06, como muito bem observou o representante do Ministério Público.

Com efeito, conforme se verifica do quadro probatório produzido, o acusado promovia o tráfico ilícito de entorpecentes há pelo menos duas semanas, não se tratando de fato isolado em sua vida. No momento em que foi abordado, portava as drogas e também R\$316,00 em notas trocadas, como se observa da imagem juntada à pág. 31, o que revela que já havia vendido inúmeras porções dos entorpecentes.

E ao que tudo indica, não exerce qualquer atividade lícita - até porque não produziu qualquer prova a respeito, não sendo desarrazoado presumir que faz da traficância seu meio de vida.

Por fim, a reforçar a convicção nesse sentido, verifica-se que o acusado foi preso em flagrante meses depois, praticando crime da mesma natureza, o que revela habitualidade. E ao que consta, está preso pelo crime referido e já foi condenado em primeiro grau de jurisdição (24ª Vara Criminal desta Capital - págs. 207/208), ocasião em que também lhe foi vedado o direito de interpor recurso em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra YURI CALDEIRA, R.G. nº 63.137.126, e o condeno ao cumprimento de cinco anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a quinhentos dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO, tendo em vista o que dispõe a Lei nº 11.464/07, que alterou a redação original do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90.

Pela gravidade do crime aqui tratado, considerado hediondo, pelas razões consignadas quando da fixação da pena, bem como pelo montante aplicado, o acusado NÃO poderá recorrer em liberdade, e, igualmente, não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, que não tem aplicação ao crime tratado na presente ação penal, que tem regras especiais e que são aplicadas em detrimento das gerais. Nesse sentido: "APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença absolutória - Recurso do Ministério Público postulando a condenação do acusado, nos termos da inicial acusatória, pelo crime de tráfico de drogas, bem como a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, o reconhecimento da agravante da reincidência e a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena - Cabimento - Materialidade e autoria comprovadas - 45 (quarenta e cinco) microtubos plásticos encontrados no exato local em que o réu se abaixou, próximo de sua carteira que também foi dispensado pelo Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto condenatório - Pena-base fixada acima do mínimo legal, tendo em vista os péssimos antecedentes do réu - Aplicação da agravante da reincidência - Não aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Substituição por restritivas de direitos - Descabimento - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime - RECURSO PROVIDO" (TJSP; Apelação 0001725-63.2017.8.26.0540; Relator(a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019).

"ENTORPECENTE. Tráfico. Desclassificação em primeiro grau para o delito de posse de tóxico para uso pessoal. Recurso ministerial buscando a condenação pelo crime de tráfico. Circunstâncias da abordagem e quantidade de entorpecente apreendido indicando destinação comercial, segundo os critérios do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06. Condenação por tráfico que se impõe. Dosimetria. Básicas que partem dos mínimos legais, sendo acrescidas de um quinto, na segunda fase, pela dupla reincidência, a qual, aliás, impede a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Regime fechado necessário, sendo incogitável a substituição das penas corporais por restritivas de direitos. Apelo ministerial provido, com determinação" (TJSP; Apelação 0004107-35.2017.8.26.0635; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019).

Por fim, por todas as razões já consignadas, ou seja, favorecido pelo benefício da liberdade provisória, respondeu a presente ação penal em liberdade, mas, não obstante, meses depois foi flagrado praticando crime da mesma natureza, o que revela habitualidade criminosa, de forma que para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e o cumprimento da pena aqui fixada, DECRETO a prisão preventiva do acusado, fazendo-o com fundamento nos artigos 311, 312 e 387, §1º, do Código de Processo Penal.

E a despeito das recentes alterações promovidas no Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964/19 - especialmente no que se refere à prisão preventiva -, é certo que o artigo 387, §1º, está em pleno vigor, não havendo óbice à decretação da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença, especialmente considerando-se o requerimento formulado pelo representante do Ministério Público em alegações finais orais.

Nesse sentido: "Ressalte-se que, mesmo depois das recentes alterações do Código de Processo Penal no âmbito da prisão preventiva (Lei nº 13.964 de 2019), o artigo 387, § 1º, do CPP, que permite ao juiz, ao azo da sentença, impor ele mesmo a prisão preventiva, está em pleno vigor e merece cumprimento.". (TJ-SP - HC: 20570505220208260000 SP 2057050-52.2020.8.26.0000, Relator: Mauricio Valala, Data de Julgamento: 28/05/2020, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020)

Ainda: "Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Insurgência contra a prisão decretada na sentença. Embora o paciente tenha respondido solto ao processo e não ter havido requerimento ministerial, o paciente permaneceu preso por outro feito no qual foi condenado em 1º Grau por associação para o tráfico de drogas. Ademais, embora o art. 311 do CPP (na redação dada pela Lei nº 13.964/2019), não mais contemple a

hipótese de decretação da prisão preventiva de ofício, permanece em vigor o disposto no art.387, § 1º, do CPP, possibilitando a decretação da custódia por ocasião da prolação da sentença. Ordem denegada". (TJ-SP - HC: 20663287720208260000 SP 2066328-77.2020.8.26.0000, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 23/06/2020, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/06/2020).

"Habeas Corpus. Na sentença condenatória, depois de condenar o paciente a quase 12 anos de reclusão por roubo a mão armada e em coautoria, o juízo decreta sua prisão preventiva por entender que sua liberdade atenta contra a incolumidade pública.

Insurgência contra referida decisão, alegando-se que o paciente respondeu ao processo em liberdade e que não haveria pedido expresso do MP para que sua prisão fosse decretada. Não acolhimento. Inteligência do art. 387, par.1º, CPP. Réu que inclusive é revel e ainda não foi preso. Requisitos da preventiva bem explorados na decisão. Coação ilegal não verificada. ORDEM DENEGADA. "(...) O juízo não fez mais do que atribuir vigência ao disposto no parágrafo 1º do art. 387 do CPP, tendo a decretação da prisão preventiva defluído como consequência lógica da própria sentença e dos fatos que nela foram reconhecidos, cuja gravidade faz necessária, como exposto, a prisão preventiva, ao menos para o resguardo da ordem pública. Dispensável, em tal situação, assim como naquela prevista para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, que houvesse pedido expresso do órgão acusatório.". (TJ-SP - HC: 22611437420208260000 SP 2261143-74.2020.8.26.0000, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 15/01/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/01/2021).

Expeça-se mandado de prisão.

Não é o caso de detração. O acusado não esteve preso no curso da presente ação penal, uma vez que obteve o benefício da liberdade provisória por ocasião da audiência de custódia. Ademais, ainda que assim não fosse, trata-se de matéria que deve ser decidida pelo Juízo das Execuções Criminais, como determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei nº 7.210/84, com observância do que dispõe o artigo 112 e parágrafo 1º, da mesma lei.

Nos termos do artigo 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06 e do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, DETERMINO a perda em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, ou seja, R\$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) relacionada no auto de exibição e apreensão (págs. 29/30), uma vez que oriunda do comércio espúrio em questão.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

Por fim, considerando-se a prova produzida na presente audiência, abra-se vista ao Ministério Público para as providências que entender pertinentes com relação a responsabilidade de Lucas Rosa Martins pelo crime aqui tratado.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de setembro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA